刑法考古題主題整理：正犯與共犯

> 本文件整理 108–114 年司律一試刑法考古題中與「正犯與共犯」相關之試題，
> 涵蓋共同正犯、教唆犯、幫助犯、間接正犯、共犯脫離、共犯從屬性、身分犯之共犯等子議題。

壹、共同正犯

【108年 第8題】共同正犯與過失傷害的分離

甲、乙共同決意殺丙，約好各自持手槍接續射擊丙。甲先射擊，未射中丙後，由乙接手，然而乙不但未射擊丙，反而因自己疏失未注意到丁，而誤傷到丁。下列敘述何者正確？

(A) 甲、乙成立殺人未遂罪與過失傷害罪之同時犯
(B) 甲、乙成立殺人未遂罪與過失傷害罪之共同正犯
(C) 甲、乙成立共同殺人未遂罪與過失傷害罪之數罪併罰
(D) 甲成立殺人未遂罪，乙成立殺人未遂罪與過失傷害罪之想像競合

答案：(D)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲、乙有犯意聯絡及行為分擔（約好各自接續射擊），並非偶然同時犯罪之**同時犯**，而是共同正犯。
(B)	✗	過失犯無法成立共同正犯，因過失犯欠缺**犯意聯絡**，無從形成共同犯罪之意思合致。
(C)	✗	甲、乙就殺人未遂為共同正犯，但過失傷害僅乙有過失行為，甲未涉及過失傷害，不能稱二人均成立過失傷害罪而數罪併罰。
(D)	✓	甲、乙成立殺人未遂之共同正犯（一部行為全部責任）。乙另因自己疏失誤傷丁，成立過失傷害罪，乙之殺人未遂與過失傷害為**想像競合**。甲不成立過失傷害，因乙之過失行為非在共同犯罪計畫範圍內，不歸責於甲。

> **重點整理：**
>
> - 共同正犯成立要件：犯意聯絡＋行為分擔，與同時犯不同。
> - **過失犯無共同正犯**：過失犯欠缺犯意聯絡，無從成立共同正犯。
> - 共同犯罪計畫範圍外之行為（如乙之過失傷害），僅由行為人自行負責，不歸責於其他共同正犯。

【109年 第9題】共同正犯的脫離與中止未遂——預備階段不成立未遂

甲、乙、丙三人受丁之請託，以每人30萬元為代價計畫殺害A，三人分工如下：甲先設法盜取A家鑰匙，乙則買得槍枝一把，甲、乙、丙當日共同侵入A家，再由丙開槍殺害A。犯案當日，三人侵入 A家之前，突然發現A與數位友人一同離家出門，甲、乙決定放棄殺人，而丙不願意，但當日亦無法再繼續犯行，甲、乙並要求丙交還鑰匙與槍枝，丙應允而返還。三日後，丙自行持刀侵入 A 家殺害 A。有關本案刑事責任之敘述，何者錯誤？

(A) 甲、乙決定放棄殺人，並要求丙交還鑰匙與槍枝，成立殺人罪之中止未遂
(B) 乙取回槍枝，故丙三日後之殺人行為與乙無關
(C) 丙出於殺人而侵入住居，構成侵入住居罪與殺人既遂罪，想像競合從重罪殺人既遂處斷
(D) 丁僅負正犯丙殺人既遂罪之教唆犯

答案：(A)（本題錯誤選項）

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗（本題答案）	甲、乙、丙三人尚未著手實行殺人行為（三人尚未侵入A家即發現A不在），仍處於**預備階段**。中止未遂（§27）以**已著手**為前提，既然尚未著手，不成立任何未遂（包括中止未遂）。甲、乙處於預備階段即放棄，不成立殺人罪之中止未遂。
(B)	✓	甲、乙已脫離共同正犯關係——明確表示放棄殺人意思，且要求丙交還鑰匙與槍枝，丙應允返還，甲、乙之先前行為貢獻已被**消除**。丙三日後自行持刀殺人係新的犯行，與甲、乙無關。
(C)	✓	丙出於殺人目的侵入住居，一行為觸犯侵入住居罪與殺人既遂罪，為**想像競合**，從重以殺人既遂罪處斷。
(D)	✓	丁教唆甲、乙、丙殺A。甲、乙已脫離共同正犯關係，僅丙完成殺人，丁就丙的殺人既遂行為負**教唆犯**之責。

重點整理：

- **中止未遂之前提**：須已「著手」實行犯罪（§27），若尚在預備階段即放棄，不成立中止未遂。
- 共同正犯之脫離：(1)明確表示脫離意思、(2)消除先前行為之因果貢獻（如取回工具）、(3)其他共犯知悉並同意。本案甲、乙成功脫離。
- 脫離後其他共同正犯之新犯行，與已脫離者無關。

【110年 第26題】身分犯與共同正犯——殺害直系血親尊親屬

甲對其父乙心生不滿，遂找朋友丙一同至其父之住處，為下列之行為。下列敘述何者正確？

(A) 甲、丙共同殺害乙並致乙死亡時，甲、丙成立刑法第271條殺害直系血親尊親屬罪之共同正犯
(B) 甲、丙共同傷害乙並致乙受輕傷時，甲、丙成立刑法第280條傷害直系血親尊親屬罪之共同正犯
(C) 甲、丙共同施強暴於乙而未成傷時，甲成立刑法第280條傷害直系血親尊親屬未遂罪，丙成立刑法第277條普通傷害未遂罪
(D) 甲、丙共同施強暴於乙而未成傷時，甲、丙成立刑法第281條施暴行於直系血親尊親屬罪之共同正犯

答案：(D)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	殺害直系血親尊親屬罪（§272）為**身分犯**。丙無此身分，依§31 I 雖可論以共同正犯，但應**科以通常之刑**（即普通殺人罪之刑度），而非逕稱二人皆成立§272共同正犯。選項表述不精確。（注意：修法後§272已刪除，但本題考的是考試當年法律）
(B)	✗	同理，§280為身分犯，丙不具直系血親晚輩身分，不能直接稱二人皆成立§280共同正犯。
(C)	✗	傷害罪（§277）不罰未遂犯，故丙不成立普通傷害未遂罪。
(D)	✓	§281施暴行於直系血親尊親屬罪為獨立罪名（非身分犯加重），甲丙共同對乙施強暴而未成傷，甲、丙成立§281之共同正犯。依§31 I，丙雖無特定身分，仍可與甲成立共同正犯，但得減輕其刑。

重點整理：

- 身分犯之共犯（§31）：無特定身分之人與有身分之人共同實行→仍可成立共同正犯，但無身分者科以通常之刑。
- §277 傷害罪不罰未遂犯。
- §281 施暴行於直系血親尊親屬罪：對直系血親尊親屬施強暴而未成傷時適用。

【110年 第22題】加重強制性交之共同正犯與共犯脫離

甲、乙二人某日前往夜店狂歡，結識丙、丁兩女，因垂涎其姿色，乃在廁所內商議，由甲吸引丙、丁之注意力，乙則乘機於該兩女飲料中摻入「約會強暴藥丸」FM2。丙、丁飲用該飲料後，迅速昏睡，甲、乙遂將丙、丁載往汽車旅館，企圖性侵。惟抵達旅館後，乙因飲酒過多，身體不適，遂在幫忙將丙、丁抬入旅館房間後自行離去。甲當晚先性侵丙女得逞，清晨時又欲性侵丁女時，因陰莖不舉而無法插入丁女之陰道，隨後離去。下列敘述何者正確？

(A) 乙因在甲性侵前自行離去，已脫離加重強制性交罪之共同正犯，只負妨害自由之罪名
(B) 甲、乙兩人構成強制性交罪之共同正犯，其中甲之行為以既遂犯論，乙之行為則以未遂犯論
(C) 甲對丙之行為，構成強制性交罪既遂，對丁之行為，僅構成強制性交罪之不能未遂
(D) 甲、乙成立加重強制性交罪之共同正犯

答案：(D)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	乙雖在甲性侵前離去，但乙已參與下藥、將被害人抬入旅館等行為，其行為貢獻仍在延續。乙未積極阻止犯罪結果（如報警、通知他人），故**未成功脫離**共同正犯，仍應就全部犯行負責。
(B)	✗	共同正犯「一部行為全部責任」，乙應就甲之既遂行為共同負責，不因個人未實行性交而僅論未遂。
(C)	✗	甲因陰莖不舉而無法插入，屬一時性生理障礙，非手段本質上之不能，應成立**普通未遂**而非不能未遂（§26）。
(D)	✓	甲、乙二人以上共同犯之，構成§222第1項第1款**加重強制性交罪之共同正犯**。乙就甲性侵丙既遂及性侵丁未遂均應負共同正犯之責。

重點整理：

- 共同正犯「一部行為全部責任」原則。
- 共犯脫離要件：(1)脫離意思之表示、(2)消除先前行為的影響力、(3)其他共犯知悉。僅離開現場而未消除先前行為影響力，不構成脫離。
- §222 I ① 加重強制性交罪：二人以上共同犯之者。

【111年 第10題】共同正犯之脫離與中止未遂

甲、乙、丙三人計畫共同殺害 A，甲之分工為取得 A 家鑰匙並在現場把風，乙、丙則於犯罪當日進入A家持刀殺害A。犯案前一日，甲將A家鑰匙先行交給乙。當日三人依約前往集合地點，但甲竟先喝酒壯膽後而開車出門，未料在路上遇警察隨機臨檢，因酒駕而被逮捕。乙、丙當日見甲遲未出現，乃直接翻牆進入A家殺人，乙覬覦A之名錶已久，在兩人共同殺死A後，乙趁丙不注意時，將 A身上之名錶帶走。有關甲、乙、丙刑事責任之敘述，下列何者錯誤？

(A) 甲因未能出現於犯案現場，故已成功脫離於本案之共同正犯
(B) 乙、丙兩人構成侵入住居罪共同正犯
(C) 乙另外構成強盜殺人罪
(D) 甲不適用刑法第27條第2項之共同正犯中止未遂規定

答案：(A)（本題錯誤選項）

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗（本題答案）	甲雖因酒駕被逮而未到場，但其**先前已交付鑰匙、參與犯罪計畫**，其貢獻仍延續影響犯罪實現。甲並未主動採取脫離行為（如通知同夥放棄、取回鑰匙、報警等），僅是被動未到場，故**未成功脫離**共同正犯，仍應負共同正犯之責。
(B)	✓	乙、丙翻牆進入A家，構成侵入住居罪之共同正犯。
(C)	✓	乙在殺人後取走名錶，利用殺人行為壓制被害人抗拒之機會取財，構成強盜殺人之結合犯（§332），此為超出共同犯罪計畫之行為，僅乙負責。
(D)	✓	甲非出於己意中止（係因酒駕被逮），且未防止犯罪結果發生（A仍被殺），不適用§27 II 共同正犯中止未遂之規定。

重點整理：

- 共同正犯之脫離：**須積極消除先前行為的因果貢獻**，僅「未出現」不等於脫離。
- 共同正犯中止未遂（§27 II）：須(1)中止自己行為，並(2)積極防止犯罪結果發生。
- 共同犯罪計畫之逾越（excesses）：逾越部分僅由實行者個人負責。

【112年 第10題】繼續犯中的相繼共同正犯

甲因與乙有仇，遂自1月1日起至5月31日間在家中私行拘禁乙，下列敘述何者錯誤？

(A) 乙為求脫身，故將價值 10 萬元的手錶給甲，甲再於 6 月 1 日將該手錶轉送給明知此段犯罪行為的女友A，因犯罪已經結束，且A不是共犯，故法院不得對A諭知沒收該手錶
(B) 假設在 3 月 5 日有關私行拘禁的刑法條文變更並加重處罰，則法院可以直接適用修正後的刑法規定，無須為新舊法比較
(C) 甲在拘禁乙的期間，先請有共同參與甲犯罪意思的丙協助綑綁乙，過了3天，再請有共同參與甲犯罪意思的丁協助看守乙（丙、丁2人並不認識），則甲、丙、丁仍可成立共同正犯
(D) 乙在3月1日試圖逃跑，然仍為甲發現並抓回，甲於抓回乙後，一時氣憤，乃起意揍乙成傷，則就該傷害行為，仍應另外論罪，不能認是私行拘禁行為的當然結果

答案：(A)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗（本題答案）	犯罪所得之沒收，於第三人明知他人犯罪所得而取得者，依§38-1 II 仍得對第三人沒收。A明知為犯罪行為所得手錶而受贈，法院**得對A諭知沒收**。
(B)	✓	私行拘禁為**繼續犯**，行為跨越新舊法施行時點，以行為終了時之法律為準，可直接適用修正後法律，無須新舊法比較。
(C)	✓	**相繼共同正犯**：在繼續犯的實行過程中，先後加入犯罪計畫並分擔行為者，即使彼此不認識，只要各自與甲有犯意聯絡及行為分擔，仍可成立共同正犯。
(D)	✓	甲另行起意之傷害行為，非私行拘禁行為之當然伴隨結果，應另外論以傷害罪。

重點整理：

- **相繼共同正犯（承繼的共同正犯）**：後加入者對加入後之犯行負共同正犯之責。在繼續犯中，先後參與者即使互不認識，仍可透過與主導者之犯意聯絡成立共同正犯。
- 繼續犯跨越新舊法施行時點→適用行為終了時之法律。

【113年 第31題】結夥三人以上之計算——限制責任能力人

成年人甲、乙、丙與13歲的丁共同謀議進入某豪宅行竊，其中甲負責竊盜的謀議與計畫，而僅由乙、丙、丁前往現場行竊。犯罪當日，甲在家中等待，乙、丙、丁前往目標現場，由乙負責在豪宅門口把風，丙、丁則入內行竊，於竊得大筆財物後，坐上乙接應的車輛離去，並回到甲家中由四人均分所得贓款。本案關於是否符合刑法第321條第1項第4款「結夥三人以上」加重竊盜罪，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 甲應計入結夥人數
(B) 乙應計入結夥人數
(C) 丙應計入結夥人數
(D) 丁應不計入結夥人數

答案：(A)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗（本題答案）	依實務見解，「結夥三人以上」須以**在場共同實行**者計算。甲僅負責謀議與計畫而未到場，屬**共謀共同正犯**，依實務見解**不計入**結夥人數。
(B)	✓	乙在現場把風，屬現場分擔行為之人，應計入結夥人數。
(C)	✓	丙在現場入內行竊，應計入結夥人數。
(D)	✓	依實務見解，「結夥三人以上」之人數計算，須具有**完全責任能力**之人。13歲之丁為無責任能力人（§18 I），**不計入**結夥人數。

重點整理：

- 「結夥三人以上」（§321 I ④）：
  - 須**在場共同實行**，共謀共同正犯不計入。
  - 須具**完全責任能力**，無責任能力人不計入。
- 共謀共同正犯仍成立共同正犯（負全部責任），只是不算入「結夥」人數。

貳、教唆犯

【113年 第35題】教唆犯與事後收受贓物

甲教唆友人乙，趁鄰居丙上班時前往丙家偷竊財物，乙乃聽從其建議，於某日侵入住宅竊取相機、電腦，乙於得手後，將相機贈送甲以表達感謝，甲決定收下該相機。依實務見解，甲之刑責為何？

(A) 甲僅成立刑法第349條第1項收受贓物罪
(B) 甲成立刑法第321條第1項加重竊盜罪之教唆犯
(C) 甲成立刑法第321條第1項加重竊盜罪之教唆犯與收受贓物罪，二罪數罪併罰
(D) 甲成立刑法第321條第1項加重竊盜罪之教唆犯與收受贓物罪，二罪想像競合

答案：(B)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲教唆乙竊盜，為加重竊盜罪之教唆犯，不能僅論收受贓物罪。
(B)	✓	甲教唆乙侵入住宅竊盜，乙實行既遂，甲成立§321 I 加重竊盜罪之教唆犯。甲事後收受贓物（相機）之行為，依實務見解屬**不罰之後行為（與罰的後行為）**，因教唆竊盜之行為已涵蓋對贓物之評價，不另論收受贓物罪。
(C)	✗	不另論收受贓物罪，無數罪併罰問題。
(D)	✗	同(C)，不成立兩罪。

重點整理：

- 教唆犯（§29）：教唆他人使之實行犯罪行為。正犯既遂，教唆犯亦論既遂。
- **不罰的後行為（與罰的後行為）**：教唆竊盜者事後收受贓物，因竊盜教唆已充分評價其不法內涵，收受贓物屬不罰之後行為。
- 同理：正犯竊盜後自行處分贓物（如變賣），亦不另論贓物罪。

【113年 第8題】教唆犯 vs 間接正犯的區分

某行政機關科長甲，因涉嫌偽造文書，經檢察官偵查。對此，甲供稱，當時直屬長官乙命令自己實行該行為，甲雖明知自己偽造文書，但無奈乙宣稱會負責一切責任，甲不得已只好照辦。經查，甲所述屬實，下列敘述何者正確？

(A) 甲得主張依所屬上級公務員命令之行為，阻卻違法
(B) 甲得主張無期待可能性，阻卻責任
(C) 乙是偽造文書罪的間接正犯
(D) 乙是偽造文書罪的教唆犯

答案：(D)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	依§21 II，公務員依長官命令之行為得阻卻違法，但以該命令**不違反刑事法律**為限。偽造文書為明知違法之命令，甲不得據此阻卻違法。
(B)	✗	甲身為公務員，明知偽造文書違法仍照辦，難謂無期待可能性。甲可選擇拒絕執行或向上級反映。
(C)	✗	間接正犯係「利用他人為工具」實行犯罪，被利用者須**欠缺故意或欠缺責任**等情形。本案甲**明知**是偽造文書仍照辦，甲具備完整的構成要件故意與責任，並非被當成工具利用，故乙非間接正犯。
(D)	✓	乙下達指令使甲實行偽造文書行為，甲具備完整故意而為直接正犯，乙為**教唆犯**。

重點整理：

- **間接正犯 vs 教唆犯的區分**：
  - 間接正犯：被利用者欠缺故意、責任或違法性（如被欺騙、精神障礙、合法行為）→幕後者為正犯。
  - 教唆犯：被教唆者具備完整故意與責任→實行者為正犯，唆使者為教唆犯。
- 上級公務員命令下級為違法行為：下級明知違法仍照辦→下級為正犯，上級為教唆犯。

【111年 第21題】教唆與犯後行為（隱避犯人、湮滅證據）

甲唆使乙殺丙，又出重金請託知情之丁幫忙毀屍滅跡。乙殺死丙後將兇刀丟棄，丙之家屬發現丙失蹤後，立即報案。甲因此囑咐丁趕緊將丙屍體掩埋於荒山，甲並安排乙順利偷渡出境。依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 乙丟棄兇刀，成立刑法第165條湮滅刑事證據罪
(B) 丁掩埋屍體，成立刑法第165條湮滅刑事證據罪之幫助犯
(C) 甲請託丁毀屍滅跡，成立刑法第165條湮滅刑事證據罪之教唆犯
(D) 甲安排乙偷渡出境，成立刑法第164條隱避犯人罪

答案：(D)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	乙為殺人罪之**正犯（本犯）**，本犯於犯罪後湮滅證據屬**不罰之自我庇護行為**，不成立§165。
(B)	✗	丁親自掩埋屍體，為§165湮滅刑事證據罪之**正犯**（直接實行），非幫助犯。
(C)	✗	甲為殺人罪之**教唆犯**，就殺人犯行而言甲亦為廣義的本犯（共犯），其請託他人毀屍滅跡屬**自我庇護行為之延伸**，依實務見解不成立§165之教唆犯。
(D)	✓	甲安排乙偷渡出境→使犯人（乙）隱避，成立§164**隱避犯人罪**。雖甲為殺人教唆犯，但隱避犯人罪所保護的是國家司法權之行使，甲使乙逃亡規避追訴，獨立成罪。

重點整理：

- 本犯（正犯、共犯）犯罪後自行湮滅證據→不罰（自我庇護行為）。
- 本犯請託第三人湮滅證據→本犯不罰，但第三人成立§165正犯。
- 隱避犯人罪（§164）：即使是共犯關係，使犯人隱避仍可獨立成罪。
- 教唆犯、幫助犯就本犯犯後的湮滅證據行為通常不另論罪，但隱避犯人罪例外。

參、幫助犯

【111年 第11題】幫助犯——精神助力的認定

小華欲前往殺害仇人 A，向小明借手槍一把，小華取得手槍後，因此提振殺人之勇氣，但小華到現場，卻搶過A手中的木棍，而將A打死。小明所成立犯罪之下列敘述何者正確？

(A) 小明的行為是給予小華精神助力，成立殺人罪的幫助犯
(B) 小明的行為乃引發犯意之行為，應成立殺人罪的教唆犯
(C) 小明的行為不是給小華有效之幫助行為，故不成立犯罪
(D) 小明的行為與小華的行為欠缺物理性關聯，不成立犯罪

答案：(A)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✓	小華**原已有殺人犯意**（自己決定要殺A），小明出借手槍雖最終未被使用，但**提振了小華的殺人勇氣**（精神助力），對正犯的犯罪決意產生強化作用，成立殺人罪之**幫助犯**。
(B)	✗	教唆犯須「引發」他人原本不存在的犯意。小華本已有殺人犯意，小明並非引發犯意之人，不成立教唆犯。
(C)	✗	幫助行為不以物理上被直接使用為限，**精神上的助力**（如強化犯意、提供安心感）亦屬有效之幫助行為。
(D)	✗	同(C)，幫助之因果關係不要求物理性關聯，精神助力即可。

重點整理：

- 幫助犯（§30）：幫助他人實行犯罪行為。
- 幫助行為的態樣：
  - **物理幫助**：提供工具、交通工具、場所等。
  - **精神幫助**：強化犯意、提供資訊、給予鼓勵等。
- 即使所提供的工具**未被實際使用**，只要對正犯產生精神上的助力（如提振勇氣），仍成立幫助犯。
- **教唆犯 vs 幫助犯**：教唆犯是引發「新」犯意；幫助犯是強化「既有」犯意或提供助力。

肆、間接正犯

【109年 第8題】間接正犯——利用不知情之人為工具

甲企圖殺住院中的 A，潛入醫院護理站偷偷將 A 服用的藥掉包成毒藥，值班護士乙在交付藥品給 A 服用時，未依醫院給藥規定比對藥物是否正確，以致於未發覺此事，乙遂在不知情之下將毒藥交給A 服用，A隨即毒發身亡。下列敘述何者正確？

(A) 甲、乙成立故意殺人罪之共同正犯
(B) 甲成立殺人罪之間接正犯，乙成立殺人罪之幫助犯
(C) 甲成立殺人罪之間接正犯，乙成立過失致死罪
(D) 甲成立殺人罪之間接正犯，乙無罪

答案：(C)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	乙不知情（無殺人故意），與甲無**犯意聯絡**，不成立故意殺人罪之共同正犯。
(B)	✗	乙不知情，無殺人故意，幫助犯須有**幫助故意**，乙不成立殺人罪之幫助犯。
(C)	✓	甲利用不知情之乙（工具人）完成殺人行為，甲成立殺人罪之**間接正犯**。乙身為護士，未依醫院給藥規定比對藥物，違反業務上之**注意義務**，成立**過失致死罪**。

(D) ✗ 乙為護士，具有業務上之注意義務，未依規定比對藥物而致A死亡，有**過失**，非無罪。

> **重點整理：**
>
> - **間接正犯**：利用不知情、無故意之人為工具實行犯罪。被利用者欠缺故意→幕後操縱者為間接正犯。
> - 被利用之工具人若有**過失**（如違反注意義務），仍應就其過失行為負過失犯之責，非當然無罪。
> - 間接正犯與過失犯可並存：甲為故意殺人之間接正犯，乙為過失致死罪。

【112年 第19題】間接正犯的否定——證人具結能力

15歲的甲在啤酒屋打工，某晚目睹該啤酒屋股東乙與酒客丙發生口角，乙糾眾毆打丙，導致丙腦震盪及身上多處挫傷，丙提出告訴。承辦檢察官以證人身分傳訊甲，甲作證前，乙威脅甲：若膽敢作不利證詞，小命不保。甲心生畏懼，在檢察官詢問時證稱當晚並未看到乙，並為具結。依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲成立偽證罪，但屬限制責任能力人，得減輕其刑
(B) 甲因遭恐嚇有生命危難，可以主張緊急避難阻卻違法，甲無罪
(C) 甲屬不得令其具結的證人，雖檢察官令其具結，亦不生效力，甲無罪
(D) 乙脅迫甲作偽證，成立偽證罪之間接正犯

答案：(C)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲為15歲（未滿16歲），依刑事訴訟法§186 I，未滿16歲之證人**不得令其具結**。不得具結之人即使具結，亦不生效力，不符合偽證罪之前提要件，不成立偽證罪。
(B)	✗	因(A)之理由，甲不成立偽證罪，無須討論阻卻違法。
(C)	✓	甲未滿16歲，屬不得令其具結之證人，縱令具結亦不生效力，**不成立偽證罪**。
(D)	✗	乙脅迫甲作偽證，但因甲之具結本不生效力而不成立偽證罪，故乙亦無法成立偽證罪之間接正犯（正犯行為不該當構成要件，間接正犯亦無從成立）。乙另可能成立恐嚇罪。

> **重點整理：**
>
> - 間接正犯之成立前提：被利用者的行為須在客觀上該當特定犯罪之構成要件。若被利用者根本不符合犯罪成立前提（如偽證罪要求合法具結），間接正犯亦不成立。
> - 偽證罪（§168）為己手犯，以具有具結義務且合法具結為前提。
> - 不得令其具結之人：未滿16歲者（刑訴§186 I）。

伍、共犯與身分犯

【114年 第8題】非公務員與公務員共同收賄

公務員甲透過非公務員之友人乙充當白手套，由乙出面向丙收受賄賂，而為違背職務之行為，依實務見解乙有無犯罪？

(A) 沒有，乙非公務員，不會構成犯罪
(B) 沒有，乙沒有為任何違背職務之行為，單純當白手套，只是間接正犯之工具，現行法沒有處罰機制，係立法漏洞
(C) 有，乙雖非公務員，不會構成公務員收受賄賂罪，但應構成背信罪
(D) 有，乙雖非公務員，但與具有公務員身分之人共同犯罪，仍會構成公務員收受賄賂罪

答案：(D)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	§31 I 明定：因身分或其他特定關係成立之罪，其共同實行者，**雖無特定關係，仍以正犯或共犯論**。
(B)	✗	乙非被利用之工具，乙有犯意聯絡且主動配合收受賄賂，屬共同正犯或幫助犯，非間接正犯之工具。
(C)	✗	乙應依§31 I 論以公務員收受賄賂罪之共犯，而非背信罪。
(D)	✓	依§31 I，乙雖非公務員，但與公務員甲有犯意聯絡，共同實行收受賄賂之行為，仍構成公務員違背職務收受賄賂罪之共同正犯（但得科以通常之刑）。

重點整理：

- **§31 I（身分犯之共犯）**：無特定身分之人與有身分之人共同實行身分犯→仍以正犯或共犯論，但無身分者**得科以通常之刑**。
- 常見適用場景：
    - 非公務員與公務員共同收賄
    - 非直系血親晚輩與晚輩共同傷害尊親屬
    - 非軍人與軍人共犯軍法上之罪

【113年 第25題】共同正犯的加入時點——略誘罪

有關刑法第240條、第241條和誘、略誘罪之敘述，依實務見解，下列何者錯誤？

(A) 甲欲與A性交，乃將A略誘帶至某旅館，甲隨即請知情的B代為看管A，B乃依甲的指示看管A，因略誘行為已結束，B不會與甲成立略誘罪之共同正犯
(B) 母親意圖使未滿7歲之子女脫離父親親權之行使，而未經父親同意，將該子女帶往他地以阻隔父親行使親權者，仍可能成罪，不因母親同有親權而受影響
(C) 甲在略誘A的期間中，因A想要逃跑，甲遂出言恐嚇：「如果你敢跑走，我會揍你」，甲不會另外成立恐嚇罪
(D) 所謂和誘，係指被誘人知拐誘之目的而予同意者而言；如果違反被誘人之意思，而將其置於自己實力支配之下，則為略誘

答案：(A)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗（本題答案）	略誘罪為**繼續犯**，行為自將被害人置於實力支配下開始，至被害人脫離支配時終了。B在略誘行為繼續中加入看管，有犯意聯絡及行為分擔，應與甲成立略誘罪之**共同正犯（相繼共同正犯）**。
(B)	✓	父母雙方共有親權，一方未經他方同意將子女帶走以阻隔行使親權，仍可能成立和誘或略誘罪。
(C)	✓	略誘期間對被害人恐嚇使其不敢逃跑，屬維持略誘狀態之手段行為，被略誘罪所吸收，不另成立恐嚇罪。
(D)	✓	和誘 vs 略誘之定義正確。

重點整理：

- **相繼共同正犯在繼續犯中的適用**：繼續犯行為持續中，後加入者仍可成立共同正犯。
- 略誘罪為繼續犯：自將被害人置於支配下時起至脫離支配時止。
- 繼續犯進行中的維持手段（如恐嚇不准逃跑）被主行為吸收。

陸、共犯從屬性

【108年 第9題】教唆犯與共犯從屬性——湮滅證據罪之正犯適格

甲犯殺人罪，事後知情的乙唆使甲，儘速將甲所用的兇刀丟棄，依通說乙不會成立刑法第 165 條湮滅證據罪之教唆犯，下列理由與結論，何者最為適當？

(A) 乙並沒有引發甲的犯意，甲原來就有湮滅證據罪的犯意
(B) 乙雖引發甲的犯意，但甲的行為不受刑法第165條處罰
(C) 乙雖促使甲犯罪，但成立第165條湮滅證據罪之幫助犯
(D) 乙事後知情並且參與，屬犯意聯絡，應該成立共同正犯

答案：(B)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	教唆犯之認定重點非在於被教唆者是否已有犯意，本題之關鍵在於§165之**正犯適格**問題。
(B)	✓	§165湮滅證據罪之主體限於「關係**他人**刑事被告案件之證據」，不包括犯罪人本人。甲湮滅自己犯罪之證據，甲不受§165處罰（**本人不罰特權／期待可能性**）。依**共犯從屬性原則**，正犯甲不成立犯罪→教唆犯乙亦不成立教唆犯。惟乙可能另成立§165之**間接正犯**（利用不受處罰之甲去湮滅證據），此為另一問題。
(C)	✗	乙唆使甲丟棄兇刀，係引發甲之行為決意，為**教唆行為**而非幫助行為。且因甲不受§165處罰，依從屬性原則，乙之共犯亦不成立。

(D) ✗ 甲本人不受§165處罰，共犯之成立以正犯成立為前提，不能逕稱共同正犯。

> **重點整理：**
>
> - **共犯從屬性原則**：教唆犯、幫助犯之成立，以正犯行為具備不法性為前提。正犯不成立犯罪→共犯亦不成立。
> - §165湮滅證據罪：主體限於他人案件之證據，犯罪人本人湮滅自己犯罪之證據→**不受§165處罰**。
> - 教唆不受處罰之人→教唆犯不成立，但教唆者可能成立**間接正犯**（利用不受處罰之人為工具）。

【111年 第9題】正犯未著手，教唆犯不成立

甲與A均為流氓，因搶奪地盤發生糾紛，甲遂決意持刀砍斷A腳筋、讓其殘廢。乙對此並不知情，但乙因與A也有黑道糾紛，為教訓A，乃以新臺幣 20 萬元唆使甲傷害 A讓其殘廢。甲心想多賺 20 萬元，便一口答應。當晚，甲持水果刀前往A家門前埋伏，計畫等A回來就動手。此時，碰巧巡邏員警經過，見甲鬼鬼祟祟，便上前盤查，甲心虛逃跑而遭警察追上逮捕，甲之後接受偵訊時坦承上述情事。依實務見解，甲、乙之行為應如何論罪？

(A) 甲、乙均不成立犯罪
(B) 甲成立重傷未遂罪、乙成立重傷未遂罪之教唆犯
(C) 甲成立重傷未遂罪、乙成立重傷未遂罪之幫助犯
(D) 甲成立重傷罪之預備犯、乙無罪

答案：(A)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✓	甲僅在A家門前埋伏等待，尚未對A施以攻擊，**屬預備階段**。§278重傷罪僅處罰未遂犯，**不處罰預備犯**。甲不成立犯罪。依**共犯從屬性原則（限制從屬形式）**，正犯未著手實行，教唆犯亦不成立。故乙亦不成立犯罪。
(B)	✗	甲尚未著手，不成立未遂犯；乙因此亦無從成立教唆犯。
(C)	✗	乙係唆使甲犯罪，為教唆犯而非幫助犯。
(D)	✗	§278重傷罪無處罰預備犯之規定。

> **重點整理：**
>
> - **共犯從屬性（限制從屬形式）**：教唆犯、幫助犯的成立，以正犯已著手實行**不法行為**（該當構成要件＋違法性）為前提。
> - 正犯未著手→教唆犯、幫助犯均不成立。
> - 正犯僅在預備階段，且該罪不罰預備犯→正犯無罪，共犯亦無罪。

柒、重點整理與體系歸納

一、正犯類型

類型	定義	要件
直接正犯	親自實行構成要件行為	具備故意＋親自實行
間接正犯	利用他人為工具實行犯罪	被利用者欠缺故意、責任或違法性
共同正犯（§28）	二人以上共同實行犯罪行為	犯意聯絡＋行為分擔
共謀共同正犯	僅參與謀議未到場實行	犯意聯絡＋以自己犯罪之意思（實務承認）

二、共犯類型

類型	定義	法律效果
教唆犯（§29）	教唆他人使之實行犯罪	依其所教唆之罪處罰之
幫助犯（§30）	幫助他人實行犯罪	得按正犯之刑減輕之

三、常見考點一覽

考點	關鍵判斷	出現年度
共同正犯脫離	須積極消除先前行為的因果貢獻	109、110、111
過失犯無共同正犯	過失犯欠缺犯意聯絡→不成立共同正犯	108
共犯從屬性	正犯不成立→共犯亦不成立	108、111
教唆犯 vs 幫助犯	引發新犯意 vs 強化既有犯意	111

教唆犯 vs 間接正犯	被利用者有無完整故意與責任	112、113
間接正犯	利用不知情者為工具完成犯罪	109、112
身分犯之共犯（§31）	無身分者仍可論共犯，但科通常之刑	110、114
相繼共同正犯	繼續犯進行中後加入者仍可成立共同正犯	112、113
結夥三人的計算	須在場＋須完全責任能力	113
共同正犯逾越	超出共同犯罪計畫者僅實行者負責	108、111
中止未遂之前提（著手）	須已著手始得論未遂，預備階段無未遂可言	109
不罰的後行為	教唆竊盜後收受贓物不另論罪	113
本犯犯後自我庇護	湮滅證據不罰，但隱避犯人另論	108、111

四、§31 身分犯之共犯——條文整理

條項	內容
§31 I	因身分或其他特定關係成立之罪（**純正身分犯**），其共同實行、教唆或幫助者，**雖無特定關係，仍以正犯或共犯論**。但得減輕其刑。
§31 II	因身分或其他特定關係致刑有重輕或免除者（**不純正身分犯**），其無特定關係之人，**科以通常之刑**。

資料來源： 108–114 年司律一試刑法考古題
最後更新： 2026-06-19